

제61회 변리사 2차 시험 『상표법』 총평

- 최지환 변리사 -

변리사 2차 수험생 여러분, 안녕하세요.

저는 메가변리사 상표법 전임 최지환 변리사입니다.

다들 이틀간 어려운 시험 치르시느라 정말 고생 많으셨단 말씀 먼저 드립니다.

올해 상표법 문제는 이전의 어떤 해와 비교하더라도 평이하다고 평가할 수 있을 정도로 ‘중하’ 정도의 난이도로 출제되었습니다. 특히, 올해 중요한 개정사항이었던 ‘상표 공존동의제도’, 중요 판례로 꼽히는 ‘크라운진 사건’, 최신판례들인 ‘CONTOUR COIL 사건, 금강 사건, BURN FITNESS 사건’이 문제화 되었기에 기본 법리를 바탕으로 중요 쟁점들을 잘 정리하고 계셨다면 답안 작성에 큰 어려움이 없었을 것이라 생각합니다.

이하에서는 각 문제에 대하여 핵심 취지와 총평을 안내 드리겠습니다. [이하 총평은 대략적인 논점과 결론을 제시해드린 것이며, 구체적인 목차와 사안포섭은 추후 사례집 개정시에 반영해드릴 예정인 점 참고 부탁드립니다.]

I. 문제-1

문제 유형	판례중심형 (크라운진 判例)
예상 출제취지	1. 크라운진 판례 사안과 유사한 사안에서의 침해판단 (法90조1항1호, 상표 유사판단) 2. 등록상표의 불사용과 손해불발생항변, 법정손해배상청구 3. 권리남용항변 일반론
난이도	중하
각 설문별 핵심쟁점	
설문(1)	[상표권 침해 일반론] [표장1에 대한 침해판단] 1. 상표의 유사여부 - 표장1 내에서 “AniGene” 요부관찰 가능 → 등록상표와 유사 2. 法90조1항1호 해당여부 - “주식회사” 생략, 영문변경 & 도안화 사정 → 法90조1항1호 X 3. 결론 - 침해 인정 [표장2에 대한 침해판단] 1. 상표의 사용 판단 - 法2조2항2호 간단히 언급 2. “(주)애니진” 부분의 효력제한 - 法90조1항1호 O [매직블럭 判例 법리 검토] 3. 나머지 부분과 등록상표의 대비 - 외관, 호칭 모두 상이 → 등록상표의 권리범위에 속하지 않음 4. 결론 - 침해 불인정
설문(2)	[109조 손해배상청구 관련] 1. 손해배상청구 관련 일반론 간략히 검토 - 法109조 법조문, 과실추정 등 ‘간단히’ 검토 2. 등록상표의 불사용 사정이 손해불발생사유에 해당하는지 여부 - 크라운진 判例 관한 논의 [★] 3. 결론 - 손해불발생 항변시, 손해발생 불인정 [111조 손해배상청구 관련] 1. 법정손해배상청구 일반론 간략히 검토 - 法111조 의의, 취지 2. 법정손해배상청구 요건 적용 관련 判例 - 크라운진 判例 3. 결론 - 동일영역 침해 X & 상표권자 등록상표 불사용 → 불인정

설문(3)	[무효사유와 권리남용 관련] - 무효사유가 명백한 경우 상표권 행사의 권리남용 - 하이우드 判例 - 사안의 경우 - 무효사유 사정 없으므로 권리남용 항변 불인정 [취소사유와 권리남용 관련] - 취소사유가 명백한 경우 상표권 행사의 권리남용 - 불인정 (判例) [권리남용으로 인정되는 경우] - 주지상표 사용자와의 관계에서 권리남용 - 사임당 判例 - 기타 신의칙 위반 등 권리남용 - 진한커피 判例 - 사안의 경우 - 주지상표 X & 신의칙 위반 등 기타 사정 없으므로 권리남용 항변 불인정
-------	---

II. 문제-2

문제 유형	판례변형 (CONTOUR COIL 判例)
예상 출제취지	- 불사용취소심판 관련 CONTOUR COIL 判例 쟁점 검토 - 독점적 통상사용권자와 침해자 사이의 법률관계 검토 - 상표권 상속에 따른 이전등록의 효력 등 검토
난이도	중하
각 설문별 핵심쟁점	
설문(1)	[불사용취소사유 관련 검토] - 乙의 지위 간략 검토 - 미등록 사용권자의 사용도 본호 소정의 사용권자의 사용으로 봄 - 乙의 행위가 '상표의 사용'에 해당하는지 검토 - CONTOUR COIL 判例 쟁점 검토 - 동일성 검토 - 사회통념상 동일성 범주에 대한 대략적인 검토 - 결론 - 사용권자가 등록상표를 동일성 범위에서 정당하게 사용하고 있었음 [결론] - 등록상표의 사용에 관한 입증책임 - 法119조3항 규정 간략히 검토 - 결론 - 甲의 적절한 조치: 30일 내 심결취소소송하며 乙의 사용실적 입증 & 예상결과: 인용판결
설문(2)	[丙의 표장 사용행위에 대한 검토] - 상표권 침해행위에 해당하는지에 대한 간단한 검토 [乙의 상표법상 조치에 대한 검토] - 통상사용권자의 지위에 대한 검토 - 法97조2항, 타인의 사용에 대한 금지청구권 등은 없음 - 丙에게 사용금지청구 가능여부 - 통상적인 금지청구 불가능, 대위행사 가능성 有 - 丙에게 손해배상청구 가능여부 - 상표법상 손해배상청구 불가능, 민법상 불법행위(제3자 채권침해)를 원인으로 인한 손해배상청구 가능성 有 [※ Comment: 상표법상 조치를 물었으므로 乙이 丙에게 상표법상 권리행사를 할 수 없을 것이라는 점만을 검토해도 충분하며, 대위행사/민법상 불법행위에 따른 손해배상청구 가능성은 가점요인 정도라고 생각하시면 됩니다. 특허법에서 정리하시는 내용 바탕으로 답안 작성하셨으면 충분합니다.]
설문(3)	[丁의 법적지위에 대한 검토] - 상표권의 일반승계 등에 관한 규정 - 法96조1항1호, 2항 + [가점요인] 法106조1항 - 사안의 경우 - 이전등록하지 않았더라도 丁에게 상표권자 지위 승계 [丁과 丙의 법적관계] - 乙의 행위는 丁의 상표권을 침해, 丁은 상표권자로서 권리행사 가능 [丁과 乙의 법적관계] - 丁은 甲의 지위를 포괄적으로 승계 → 乙은 丁의 통상사용권자 지위 유지

III. 문제-3

문제 유형	판례변형 (금강 判例 변형)
예상 출제취지	1. 法119조1항1호 관련 중요 요건에 대한 검토 및 사안적용 2. 출처혼동을 야기하는 사용에 관한 합의의 효력 3. 상표 공존동의제도
난이도	중하
각 설문별 핵심쟁점	
설문(1)	[法119조1항1호 관련 일반론] [‘유사상표의 사용’에 관한 판단] 1. 유사상표 사용 판단 관련 判例 - msu sports 判例 2. 결론 - 乙의 상표와 유사하게 변형하여 출처혼동 가능성이 높아진 점을 주로 포섭 → 유사 o [‘혼동’ 관련 판단 ① - 대상상표 적격성] 1. 대상상표 적격성 관련 判例 - ROOTS 判例 & 인식도 요건: 특출인 2. 결론 - 특출인 간단히 포섭하며 대상상표 적격 o [‘혼동’ 관련 판단 ② - 출처혼동] 1. 본호 소정의 혼동의 의미 - 광의의 혼동 2. 혼동 판단법리 - 判例 [두문자: 변·유·표·품·사기·실·알] 3. 결론 - 출처혼동 염려 객관적으로 인정 o
설문(2)	[문제제기] - 출처혼동을 야기하는 사용에 관한 합의의 효력을 근거로 심판청구의 부적법성 주장 가부 [判例] - 금강 判例 [검토] - (배점이 큰 점을 고려) 法119조1항1호의 공익적 성격을 검토하며 判例의 타당성 검토 [사안] - 甲 주장 부당
설문(3)	[문제되는 거절이유의 검토] - 法34조1항7호 [상표 공존동의제도 도입논의] 1. ‘상표 공존동의제도’의 의의 2. 구법상 문제점 - 공존 동의제도 불인정, 判例도 ‘수요자 보호’를 위해 불인정, 일시양도 우회방안 3. 24. 5. 1. 개정법 - 法34조1항7호단서 등 & 수요자 보호를 위해 동일범위 제외, 法119조1항5호의2 [사안의 경우] - 상표, 상품이 모두 동일하여 공존동의서 제출하더라도 극복 불가 [보론] - (i) 일시양도의 방법도 불가능하므로(法38조1항), (ii) 유사범위로 바꾸어 다시 합의하거나, (iii) 동일범위에 대해 권리를 확보하고자 하는 경우에는 사용권 설정의 합의를 하는 것이 바람직함을 언급 가능

IV. 문제-4

문제 유형	판례중심형 (BURN FITNESS 判例)
예상 출제취지	1. 요부관찰 및 식별력 판단 2. 法90조1항1호에 관한 판단
난이도	중하
각 설문별 핵심쟁점	
설문(1)	[※ Comment: 乙이 침해소송 내에서 어떠한 취지로(상표 비유사 주장의 관점인지, 甲의 등록상표의 식별력이 전체로서 없다는 것을 주장하는 과정인지 등) 식별력에 관한 주장을 하고 있는 것인지 불분명하지만, 실제 판례에서 ‘요부관찰’이 쟁점이 되었던 점을 고려하면 상표 유사판단과 관련하여 주장되었다고 이해하는 것이 바람직하겠습니다.] [관련 일반론] 1. 상표 유사판단 원칙 2. 요부관찰 법리 3. 요부 판단기준 - [두문자: 주·강·비·상·식·결·품·거] & [식별력이 없으면 요부가 될 수 없다 判例] [“FITNESS” 부분의 식별력이 미약하다는 주장] - 식별력 없으므로, 주장 타당 [“SPRING” 부분의 식별력이 미약하다는 주장] 1. 식별력 판단의 일반적인 법리 - [두문자: 관·품·거·객] 2. 암시·강조 표장의 취급 3. 사안의 경우 - 암시·강조에 불과 → 식별력 부정할 수 없음 → 乙의 주장 부당 [결론] - 甲의 등록상표 내에서 “SPRING” 부분이 차지하는 비중, 상대적 식별력 수준 등을 종합하면 “SPRING” 부분이 요부관찰되어 乙의 사용표장들과 유사함 [※ Comment: 유사여부에 대한 결론을 묻지는 아니하였으나, 실제 사건에서 중요한 쟁점이 되었던 유사여부에 대한 결론을 설문(2)에서 별도로 묻지 않고 있는 점을 고려하여 간단히 결론을 내리면 가점요인이 될 수 있다고 생각합니다.]
설문(2)	[法90조1항1호 일반론] [사용태양 요건에 관한 일반론] 1. 16. 9. 1. 시행 개정법 - 구법상 ‘보사방 표시’ → ‘상거래 관행에 따른 사용’으로 요건 완화 2. 구법상 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시’의 판단기준 判例 3. 국문 상호명을 영문으로 표기한 경우 취급 判例 [사안의 경우 - 사용상표1] - “FITNESS” 부분 생략 & 도안화 → 상·관·사 X → 乙 주장 부당 [사안의 경우 - 사용상표2] - 상호 상·관·사 O & 부정경쟁목적 있다는 사정 X → 乙 주장 타당